

1502201-78.2020.8.26.0101

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.

Frise-se que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502201-78.2020.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502201-78.2020.8.26.0101

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3103625/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 15278669 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 15278670 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2571/2020/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2435/2020/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILTON MARCELINO DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

MILTON MARCELINO DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 08 horas, na Estrada Prefeito Osório da Cunha Neto, 90, Pinus do Iriguassu, nesta cidade e comarca de Caçapava, o réu, previamente ajustado com o adolescente Gilberto Camargo Santos Silva, supostamente, trazia consigo, substância entorpecente, para posterior entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 77), apresentou defesa prévia (fls. 82/83), sendo recebida a denúncia em 13/06/22 (fls. 94/96) e o acusado citado pessoalmente (fls.

135).

Durante a instrução (fls. 137/139), realizada virtualmente, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, enquanto a defesa requereu sua absolvição ou a desclassificação do delito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03, fls. 04/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Exame Químico-Toxicológico (fls. 12/14 e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa, em que pese a negativa do réu.

Em interrogatório judicial, MILTON MARCELINO DA SILVA JÚNIOR disse que tem 24 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o oitavo ano, é agricultor, mora em Tremembé, já foi condenado duas vezes por tráfico de drogas, roubo, receptação e porte de drogas para uso próprio. Em relação aos fatos, disse que, em novembro, na data dos fatos, estava em baile funk em Taubaté em uma chácara e, depois, enquanto se dirigia para outro baile funk no Pinus em Caçapava, foi abordado pelos policiais. Admitiu que estava com lança perfume, mas esclarece que era para seu próprio uso. Não se recorda com quantos frascos estava, mas confirma a afirmação do policial de que estava com 16 frascos e o menor com 8 frascos de lança. Disse que iria usar os 16 frascos no baile funk, negando que os frascos fossem para venda. Comprou 30 frascos em Taubaté para seu uso, pagando pelo entorpecente 5 reais por cada frasco. Já chegou a consumir 35 frascos de lança em uma mesma noite. O adolescente Gilberto comprou os frascos com o interrogando e também iria consumi-los. Estava com o menor desde o primeiro baile e ambos iam para a mesma festa em Caçapava. Ao ser indagado pelo Ministério Público se tem conhecimento que Gilberto atualmente está preso por tráfico, respondeu que não.

O policial militar ANDERSON BARBOSA TEIXEIRA, em juízo, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento próximo ao Pinus, quando avistaram dois indivíduos indo para o Bairro Pinus. Com o maior, localizaram 16 frascos de lança perfume e com o menor Gilberto outros 8 frascos da mesma droga. Ambos disseram que moravam em Tremembé, que estavam voltando de um fluxo e que os frascos eram para consumo próprio em outro fluxo. Não conhecia o réu, tampouco o adolescente anteriormente. O depoente não teve conhecimento da ocorrência de baile funk no dia, pois havia acabado de entrar no serviço.

Como se vê, o acusado MILTON e o adolescente Gilberto, residentes em Tremembé, foram surpreendidos pela polícia militar na posse de considerável quantidade de frascos de “lança-perfume” (24 unidade) enquanto transitavam pela via pública. Em que pese o entendimento do Ministério Público e da Defesa, não há dúvidas de que MILTON e o menor traziam consigo elevada quantidade de “lança perfume”, em um total de 24 frascos, para o fim de vendê-lo ou servir ao consumo de terceiros no baile funk para o qual se deslocavam, o que foi confirmado pelo depoimento do policial militar.

Não se mostra razoável conceder crédito à escusa de MILTON no sentido de que os 24 frascos de lança perfume se destinavam ao uso próprio.

Ainda que o acusado tenha sido apreendido na posse de apenas 16 frascos, é evidente que toda a droga pertencia a ele e ao menor e, pela quantidade apreendida (240 mililitros) e circunstâncias da apreensão, destinavam-se ao fornecimento a terceiros.

Com efeito, MILTON e o adolescente eram de Tremembé, voltavam de um “fluxo” e se dirigiam para outro baile funk, local onde há forte consumo e alto índice de venda desse tipo de droga.

Não é crível crer que o acusado e o seu amigo, em uma festa, consumiriam sozinhos 24 frascos de lança-perfume, se é certo que vinham de outro baile onde, segundo o réu, já haviam usado a mesma droga. Ainda que gratuitamente, é indubitoso que forneceriam o entorpecente a terceiros.

Ademais, se fosse para uso próprio, certamente o acusado e o adolescente iriam

trazer consigo poucos frascos, com maior capacidade de armazenamento da droga, jamais a quantidade apreendida (24 frascos!), que certamente eram para venda, pouco importando não terem sido os agentes surpreendidos na posse de dinheiro.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Aliás, não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.

Frise-se que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Portanto, mesmo não tendo o acusado MILTON sido flagrado pelos policiais militares praticando atos de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o afastamento da prática do crime que lhe foi imputado.

Por fim, eventual condição do acusado de usuário não afasta, por si só, a de traficante, já que é de sabença geral que muitos usuários se envolvem com o tráfico à vista da necessidade de sustentar o próprio vício, recebendo porções de droga como pagamento pela venda ilícita praticada.

Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, respeitado o sistema trifásico, constata-se que o réu é portador de Maus Antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo por roubo majorado nos autos dos processos de nº 1500193-

52.2018.8.26.0634 (vide certidão as fls. 127/132). Deste modo, diante de tais circunstâncias, a pena base deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes. Presente a circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea j do Código Penal. O réu é reincidente, já que condenado por receptação nos autos do processo de n.º

0001346-82.2017.8.26.0618, ostentando reincidência específica por tráfico de drogas nos autos de nº 1500213-57.2019.8.26.0618 (vide certidão as fls. 127/132). Além disso, não se pode negar que o réu se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade.

Desse modo, nos termos do artigo 67 do Código Penal, faço preponderar a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

Com efeito, o réu é portador de Maus Antecedentes por roubo majorado (autos n.º 1500193-52.2018.8.26.0634- fls. 127/132) e reincidente, uma delas específica, já que condenado criminalmente por receptação nos autos de n.º 0001346-82.2017.8.26.0618 e tráfico de drogas nos autos n.º 1500213-57.2019.8.26.0618 (fls. 127/132), o que, por óbvio, demonstra tratar-se de pessoa dedicada ao crime.

Não se olvide que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes criminais, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado MILTON. Assim, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Incide, no caso, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que o crime foi perpetrado em concurso com o adolescente Gilberto Camargo Santos Silva. Assim, procedo ao aumento da pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total definitivo de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, conforme acima fundamentado, o réu possui maus antecedentes (autos n.º 1500193-52.2018.8.26.0634 - fls. 127/132), além de ser reincidente específico (autos n.º 1500213-57.2019.8.26.0618 - fls. 127/132), o que reforça a necessidade de fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, tanto o mais porque não cumprida cautelarmente qualquer fração de pena que justifique a fixação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112 da LEP.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, II e III, parte final do Código Penal, uma vez que o acusado não preenche os pressupostos legais, seja porque a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão, seja por se tratar de réu portador de maus antecedentes (autos n.º 1500193-52.2018.8.26.0634 - fls. 127/132) e reincidente (autos n.º 0001346-82.2017.8.26.0618 e 1500213-57.2019.8.26.0618 - fls. 127/12), seja por se tratar a medida insuficiente para prevenção e repressão do crime em tela.

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. I. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j . 04/09/2007, DJe 04/08/2008).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu MILTON MARCELINO DA SILVA JUNIOR às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial

fechado, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto respondeu ao processo nesta condição e, ainda, porque ausentes novos elementos que autorizem a decretação da prisão preventiva.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de sentença e, a seguir, encaminhe-se ao Ministério Público para execução da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos para defesa do réu, observados os termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública.

P.I.C.

Caçapava, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA